

1500228-49.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gabriela da Conceição Rodrigues

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... Esclareceu que já foi condenado por tráfico de drogas e que perante o juiz da Vara de Infância não assumiu o tráfico, somente assumiu o tráfico hoje, nesta oportunidade. Esclareceu que somente estava assumindo o tráfico nesta oportunidade porque não queria ser preso de novo, pois ficou traumatizado, mas também não quer que o réu seja injustamente condenado. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n.º 01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500228-49.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital n.º:

1500228-49.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2020373/2022 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 22594993 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 299/22/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2020373 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO GUSTAVO OLIVEIRA CONCEIÇÃO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues

Vistos.

Pablo Gustavo Oliveira Conceição foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06, pois, segundo denúncia (fls. 80/81), no dia 23/01/2022, por volta de 16h09min, na Rua Luís Coutinho de Abreu, 21, Pq. Vitória, em Franco da Rocha, o denunciado, em concurso com o adolescente Kauan Checone de Oliveira, trazia consigo, para fins de entrega a terceiros: a) 67 porções de maconha, pesando, aproximadamente, 280g de massa bruta; b) 56 pedras de crack, pesando, aproximadamente, 15g de massa bruta e d) 114 eppendorfs de cocaína, pesando, aproximadamente, 69g de massa bruta; sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fl. 06); laudo de constatação com fotografias (fls. 08/13) e laudo toxicológico (fls. 124/125), bem como as quantias de R\$ 87,00 na posse de Pablo e R\$105,00 (cento e cinco reais) na posse do adolescente, produto do tráfico de drogas, também conforme auto de exibição e apreensão (fl. 06).

A denúncia foi recebida em 27/01/2022 (fl. 82).

Citado (fl. 100), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 115/116).

Designada audiência de instrução e julgamento, procedeu-se a oitiva das testemunhas arroladas e o réu foi interrogado ao final (fls. 136/137).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados nos termos da denúncia, tecendo considerações sobre a pena. A defesa requereu a desclassificação para o delito de uso de substância entorpecente e, subsidiariamente, a aplicação de pena no mínimo legal.

É o relatório.

Passo a decidir.

Preliminarmente, há que se esclarecer um ponto a fim de evitar pretensa declaração de nulidade. Nos termos do art. 399, §2º, do Código de Processo Penal, o juiz que encerrar a instrução “deverá” proferir a sentença. Trata-se, obviamente, de recomendação que deve ser observada sempre que possível, em atenção ao princípio da identidade física do juiz, que atualmente vigora no Processo Penal, mas que encontra exceções em casos de manifesto impedimento do Magistrado.

In casu, nos termos de certidão de fls. 153, verifica-se que a Juíza que encerrou a instrução está no exercício de férias, razão pela qual os autos foram conclusos a este juízo, não havendo, portanto, violação ao princípio da identidade física do juiz, por aplicação analógica do disposto no art. 132, do Código de Processo Civil. Confira-se, a propósito:

“Mesmo que tenha concluído a audiência, o Magistrado não terá o dever de julgar a lide se for afastado do órgão judicial, por motivo de convocação, licença, cessação de designação para funcionar na vara, remoção, transferência, afastamento por qualquer motivo, promoção ou aposentadoria. Incluem-se na exceção os afastamentos por férias, licença-prêmio e para exercer cargo administrativo em órgão do Poder Judiciário (Assessor, Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça etc)” (Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Editora Revista dos Tribunais, 11ª edição, pag. 411).

“...Segundo o Princípio da Identidade Física do Juiz, previsto no art. 399, § 2º, do CPP (modificação trazida pela Lei nº 11.719/08), o Magistrado que concluir a instrução em audiência deverá sentenciar o feito. III - No entanto, em razão da ausência de regras específicas, deve-se aplicar por analogia o disposto no art. 132 do CPC, segundo o qual no caso de ausência por convocação, licença, afastamento, promoção ou aposentadoria, deverão os autos passar ao sucessor do Magistrado. IV 'A adoção do princípio da identidade física do Juiz no processo penal não pode conduzir ao raciocínio simplista de dispensar totalmente e em todas as situações a colaboração de outro juízo na realização de atos judiciais, inclusive do interrogatório do acusado, sob pena de subverter a finalidade da reforma do processo penal, criando entraves à realização da Jurisdição Penal que somente interessam aos que pretendem se furtar à aplicação da Lei.' (CC 99023/PR, 3ª Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJU de 28/08/2009). V - Ademais, no sistema das nulidades pátrio, somente se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos (Precedentes). Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada” (STJ, HC 163.425/RO, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27.5.2010, publicado em 6.9.2010).

“APELAÇÃO CRIMINAL ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DIVERSAS VEZES NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL INOCORRENTE REGRA QUE ADMITE EXCEÇÃO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PRELIMINAR ARREDADA (...) RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. (...) Portanto, embora realmente o ilustre Magistrado que proferiu a sentença não tenha sido aquele que presidiu a instrução, é de se presumir que a sucessão nestes autos ocorreu de modo regular. Ao menos, nada sugere ofensa às normas aplicáveis, até mesmo porque não demonstrou a defesa eventual prejuízo suportado com a alegada irregularidade.” (Apelação Criminal 1500094-45.2019.8.26.0441; Rel. Euvaldo Chaib; Data do Julgamento: 28/05/2021)

Apelação Criminal – Recurso defensivo – Estupro de vulnerável – Preliminar de ofensa ao princípio de identidade física do juiz – Afastada – Regra que admite exceção – Prejuízo não demonstrado (TJSP; Apelação Criminal 0003538-59.2017.8.26.0271; Rel. Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/06/2022;

Data de Registro: 24/06/2022)

Furto qualificado - Princípio da identidade física do juiz - Violação - Inocorrência - ausência de prova no sentido de que a Magistrada que encerrou a instrução estivesse em exercício por ocasião da sentença - Prejuízo, ademais, não demonstrado - Preliminar rejeitada; Furto qualificado - Negativa da acusada em juízo - Alegação de que efetuava as retiradas com anuência e ordem de superior hierárquico - Possibilidade de cometimento de crimes diversos do narrado na denúncia - Indícios trazidos com o inquérito não confirmados em juízo - Aplicação do princípio in dubio pro reo - Absolvição mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0087347-33.2014.8.26.0050; Rel. Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/06/2021; Data de Registro: 11/06/2021)

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada diante do: auto de exibição e apreensão (fl. 06), laudo de constatação com fotografias (fls. 08/13), laudo toxicológico (fls. 124/125), boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de prisão em flagrante (fl. 01) e, por fim, pela prova oral colhida em regular instrução.

A autoria é certa.

Quando ouvido perante a autoridade policial, o réu disse que tem 28 anos de idade e morava na Zona Leste de São Paulo, mas quando seu pai faleceu, cerca de 1 ano atrás, veio morar na casa que herdou dele em Franco da Rocha, no bairro Parque Pretória. Mora sozinho, mas sua irmã ocupa a casa de baixo do edifício. Estudou até a 7ª série, mas abandonou os estudos quando sua mãe foi presa por tráfico de drogas na Zona Leste de São Paulo. Sabe que sua mãe ficou muitos anos presa e nunca mais a viu, porque o interrogado também acabou sendo preso e acabou retornando diversas vezes para a cadeia, sempre por crimes de roubo. Passou cerca de 6 anos encarcerado. A última vez que foi preso foi em 2018 e atualmente está em pleno gozo do benefício da liberdade condicional, sendo que deve cerca de 9 anos de sua pena. Nunca foi preso por tráfico. O declarante conhece o adolescente Kauan apenas de vista, porque a companheira do declarante mora na Rua Luiz Coutinho de Abreu e sempre que vai visitá-la observa Kauan "na loja", ou seja, no ponto de venda de drogas. O declarante alega que já comprou drogas com Kauan algumas vezes e sabe que ele é bastante conhecido na cidade como traficante. Nesta tarde, o interrogado estava indo visitar sua companheira, pretendia comprar um "baseado" com Kauan, mas quando foi adquirir a droga foram abordados de forma muito rápida por guardas municipais. Eles encontraram dinheiro, mas o declarante não soube precisar a quantia exata que tinha no bolso, o que levantou suspeita dos guardas. Eles encontraram dinheiro com Kauan e então foram vasculhar uma lixeira que estava próxima e lá encontraram a droga que pertencia a Kauan. Acredita que foi abordado apenas porque estava em companhia de Kauan e "ele é muito visado", ou seja, muito conhecido pelos policiais. Kauan não quis assumir a propriedade da droga e o declarante acabou sendo envolvido nesse crime, mas não tem qualquer responsabilidade pelo entorpecente. O interrogado alega que o dinheiro foi conseguido junto com sua avó paterna, que entregou tal quantia na noite passada. O declarante pediu o dinheiro a sua avó porque está desempregado e passando dificuldades, e pretendia fazer uma entrevista de emprego no galpão do mercado livre de Franco da Rocha. Pretendia adquirir maconha com Kauan. O declarante não tem filhos e foi bem tratado pelos policiais durante a abordagem, até porque eles focaram mais no adolescente (fl. 18).

Em juízo, o réu alegou que os fatos são falsos. Disse que estava indo para sua casa com a sua esposa, e esta seguiu para casa. Afirmou que viu Kauan na rua e foi em sua direção para comprar maconha para uso próprio. Nisso chegou a guarda, enquadrou eles, acharam drogas na lixeira (a qual reconhece que era sua) e as outras, que teriam sido achadas em seu lado, na verdade estavam mais para frente e não eram de sua propriedade. Disse que o adolescente já era visado pelos policiais e foi apenas pegar drogas para ele mesmo. Disse que sua esposa morava na rua em que foi abordado, na Rua Luís Coutinho de Abreu, nº 51. Afirmou que ainda está junto com sua companheira. Afirmou que Kauan é conhecido na região como traficante e que já tinha comprado drogas com Kauan umas 3 ou 4 vezes (fl. 138).

Sua versão não está em harmonia com as demais provas dos autos

O adolescente e testemunha Kauan Checone de Oliveira, em solo policial, disse que tem 16 anos de idade e mora com sua mãe no bairro de Vila Ramos, mas também passa bastante tempo na casa de sua avó paterna, também no bairro de Vila Ramos. Frequenta a escola, está no 3º ano do Ensino Médio e nunca foi reprovado e que não tem filhos. Já foi apreendido em 2020 pela prática de ato infracional assemelhado ao crime de tráfico ilegal de drogas, conduta praticada no bairro Parque Munhoz, ocasião em que foi apreendido juntamente com Breno Adsson, adolescente que foi apreendido recentemente por tráfico de drogas. Em tal oportunidade, foi liberado pelo Delegado para sua mãe e posteriormente cumpriu liberdade assistida. No ano de 2021, o declarante foi novamente apreendido por ato infracional de tráfico de drogas, na Rua Luiz Coutinho de Abreu, sendo que desta vez foi encaminhado para a Fundação Casa e lá permaneceu internado por 45 dias e está respondendo na Vara da Infância e Juventude. O declarante está acompanhado de seu pai, Diego Moraes de Oliveira, que foi recentemente preso por tráfico de drogas. Soube que a companheira de seu pai também foi presa por tráfico ilegal de drogas. Nesta tarde, estava na casa de seu amigo Erick Leme, no bairro Parque Vitória, onde jogava vídeo game, até que decidiu ir embora para casa. Vendeu um boné para Erick por R\$100,00 e seguia em direção ao bairro de Vila Ramos, quando foi abordado por guardas municipais justamente na Rua Luiz Coutinho de Abreu, coincidentemente o mesmo local em que foi abordado quando de sua apreensão. Os guardas municipais encontraram dinheiro no bolso do declarante, então abordaram um outro rapaz que estava no local e também acharam dinheiro no bolso dele. Posteriormente, os guardas encontraram drogas, e como já o conheciam, disseram que o iriam trazer até a Delegacia para averiguação. Nega que estivesse em poder de droga ou mesmo manuseando qualquer tipo de entorpecente, e não estava no local nem mesmo para comprar drogas. Não conhece Pablo e nunca o havia visto antes. Acredita que foi apreendido pelos guardas devido ao seu passado. Alega que está buscando fazer curso profissionalizando para entrevistas de emprego (fl. 17).

Em juízo, o adolescente mudou sua versão, disse que era ele quem estava traficando drogas e que o réu apenas foi comprar uma maconha para ele mesmo. Afirmou que a esposa do réu mora na rua onde foram abordados. Esclareceu que já foi condenado por tráfico de drogas e que perante o juiz da Vara de Infância não assumiu o tráfico, somente assumiu o tráfico hoje, nesta oportunidade. Esclareceu que somente estava assumindo o tráfico nesta oportunidade porque não queria ser preso de novo, pois ficou traumatizado, mas também não quer que o réu seja injustamente condenado. Esclareceu que perante o juiz da Vara de Infância negou o tráfico porque queria ser absolvido.

A testemunha Barbara de Oliveira Perbelini (GCM), em juízo, confirmou o que já havia dito perante a autoridade policial (fl. 15). Disse que estava em patrulhamento em local já conhecido por tráfico e viu dois indivíduos mexendo numa lixeira de metal aberta, motivo pelo qual resolver abordá-los. Dentro da sacola que estava na lixeira tinha crack, cocaína e maconha. Com o réu foi encontrado R\$ 87,00 em notas trocadas e com o adolescente (que já tinha sido abordado em outras oportunidades), foram encontrados, se não se engana, R\$ 105,00, também em notas trocadas. Enquanto averiguava a lixeira, o réu e o adolescente ficaram sentados na calçada. Os guardas os afastaram e ambos disseram que iam comprar drogas um com o outro. Disse que não estava na diligência em que o adolescente foi apreendido, mas que ficou sabendo porque faz parte da mesma equipe e que quando o adolescente foi apreendido Wagner estava presente. Esclareceu que quando viram a viatura, o réu e o adolescente se afastaram da lixeira e sentaram no chão. Disse que eles continuaram conversando, tentando disfarçar. Afirmou que não tinha visto nem o réu nem o adolescente antes.

O depoimento do GCM Wagner Aparecido de Santana Leite foi no mesmo sentido. Disse que estava em patrulhamento no local, que já é conhecido pelo tráfico, quando viu dois indivíduos numa lixeira. Quando a viatura se aproximou, os indivíduos se afastaram da lixeira. Pelo fato de ter reconhecido o adolescente, o qual já tinha sido apreendido ali por tráfico, verificaram a lixeira (onde encontraram uma sacola verde com os entorpecentes crack cocaína e maconha) e em revista, encontraram

dinheiros com os indivíduos em notas trocadas. Os dois foram separados e questionados sobre o que faziam no local. Mutuamente um acusou o outro, dizendo que eram usuários e que foram comprar drogas um com o outro e vice e versa. Nenhum dos dois tinham drogas nas mãos, somente dinheiro (Pablo com R\$ 87,00 e Kauan com R\$ 105,00, ambos com notas trocadas). Na mesma lixeira tinham outros sacos de lixo. A lixeira ficava a um 1,20m do chão e a sacola verde estava no fundo dentro da lixeira. Disse que não foi necessária a utilização de cachorro, mas que na viatura estava o cão da corporação, pois eles são da equipe de canil. O GCM confirmou o que já havia dito na fase investigativa (fl. 14).

Preliminarmente, não há que se falar em irregularidade da atuação dos guardas municipais.

Como sabido, o tráfico de drogas é delito de natureza permanente. Nesta categoria de infrações, o sujeito pratica uma violação da norma penal que se prolonga no tempo. Estará, portanto, em constante estado de flagrância enquanto perdurar a conduta criminosa (art. 303 do CPP).

O Código de Processo Penal, em seu art. 301, permite que qualquer pessoa do povo efetue prisão de quem se acha em flagrância delitiva. É cediço que o art. 144, §8º, da Constituição Federal determina que a Guarda Municipal será destinada à proteção de bens, instalações e serviços dos Municípios, não tendo, portanto, como principal função a de assegurar a segurança pública, tampouco investigar a prática de crimes. Nada obstante, a referida disposição não significa que a guarda municipal não possa prender em flagrante aquele que estiver cometendo um delito. Tal entendimento não discrepa da posição consolidada pelos Tribunais Superiores:

“Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer um do povo pode prender aquele que estiver em flagrante delito. O fato da prisão em flagrante do ora paciente ter sido realizada por Guarda Municipal não revela ilegalidade” (STJ, HC nº 394.112/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 03/08/2017). No mais, merece destaque que, pelo Estatuto Geral das Guardas Municipais, que disciplina o referido art. 144, §8º, da Constituição, é competência específica das guardas municipais colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social (art. 5º, inc. IV), bem como encaminhar ao Delegado de Polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração penal (art. 5º, inc. XIV).

Neste caso, os guardas presenciaram a atitude suspeita do réu e do adolescente que o acompanhava, que se afastaram da lixeira quando da aproximação da viatura. Assim, era presumível que eles pudessem estar cometendo um delito, não tendo sido a ação dos guardas decorrente de qualquer investigação prévia, sendo evidente que a atitude do réu não é a que se espera de um transeunte ao avistar agentes do Estado. Ademais, não há razão para desqualificar a prova dos guardas, pois não há qualquer dado que afaste a natural credibilidade de que gozam tais testemunhas. São agentes do Estado, razão pela qual seus depoimentos devem ser avaliados sob a perspectiva da presunção de credibilidade, a menos que infirmados por outros elementos de convicção. Salvo pequenos detalhes de menor importância, não há contradições em seus depoimentos. Muito pelo contrário, a narrativa tecida por ambos é coesa, coerente, uniforme e detalhada. É o suficiente para lhes conferir importante valor probatório. No mesmo sentido, converge a lição diária de nossos tribunais:

Prova criminal Testemunhal Tráfico de entorpecentes Depoimentos de policiais que efetuaram a apreensão Credibilidade Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (ACR 147980, Rel. Jarbas Mazzoni).

“o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais

testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1ª Turma - HC 74.608-0/SP- Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189)

Assim, não procede a afirmação de inexistência de provas suficientes para a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas. Observo, ainda, que os depoimentos foram coerentes e harmônicos, de modo que eventual discrepância, se houve, não foi suficiente para retirar o valor probante que deles emana.

Entendo que o relato dos guardas é seguro e suficiente a comprovar a traficância ocorrida, não sendo necessários elementos complementares ao convencimento deste juízo, em especial pelo fato de que não conheciam o réu e este sequer possuía passagens anteriores a justificar falsa imputação criminal.

A grande quantidade de droga apreendida, e os depoimentos prestados pelos guardas ouvidos, levam à certeza de que o acusado guardava e transportava drogas na ocasião, impondo-se, pois, a sua condenação.

Frisa-se que quando da abordagem, informalmente, o réu e o adolescente disseram que eram usuários e iriam comprar a droga um do outro, se acusando mutuamente, o que não encontra amparo nos autos, uma vez que os guardas disseram que ambos estavam mexendo na lixeira - e não apenas o suposto traficante, como seria de se esperar. Isso demonstra que ambos estavam traficando. Ademais, em solo policial, o adolescente negou conhecer o réu e negou que traficava, o que vai ao encontro do que afirmou em juízo, oportunidade na qual disse que conhecia o réu e que estava vendendo a droga para ele.

Por fim, cabe assinalar que a denúncia imputa ao réu a conduta de "ter em depósito, guardar, e transportar, para entrega a consumo de terceiros, substância entorpecente", e não de vender drogas, razão pela qual os fatos descritos na denúncia encontram-se perfeitamente provados em instrução.

Reputo presente a majorante prevista no art. 40, inc. VI da Lei 11.343/06 (As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação), ante a comprovada participação do adolescente Kauan Checone de Oliveira na prática do delito.

Passo a dosar a pena.

Sopesados os elementos norteadores do art. 59 do Código de Penal, entendo que circunstâncias judiciais foram as típicas à espécie. Verifico que o réu possui maus antecedentes (0017889-60.2013.8.26.0050 - fl. 88), razão pela qual elevo a pena base em 1/8. Assim, fixo a pena-base fixada no mínimo legal em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias multa.

Na segunda fase, ausente atenuantes. Presente a agravante da reincidência (0026559-14.2018.8.26.0050/0013795-23.2018.8.26.0041 - fl. 88). Assim, elevo a pena em 1/6 fixando-a em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, reputo presente a causa de aumento prevista no inc. VI do art. 40 da Lei Antidrogas, na medida em que, pelos relatos das agentes penitenciárias, ficou evidente que o delito foi praticado no interior de estabelecimento prisional e, por isso, tendo este tráfico a especial finalidade de introduzir a droga naquele local, mas por não ter provas de que o entorpecente tenha chegado às mãos de outros presidiários, a pena será aumentada de 1/6, passando para 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 767 (setecentos e sessenta e sete) dias-multa.

Entendo que a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 não pode incidir, eis que o réu possui condenação transitada em julgado por roubo (0026559-14.2018.8.26.0050/0013795-23.2018.8.26.0041 - fl. 88).

A pena será cumprida no regime inicial fechado, nos termos do que determina o art. 33 do CP.

Nos termos dos artigos 49, §1º, e 60, caput, ambos do Código Penal, considerando a condição econômica do réu, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do art. 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição

Ante o exposto e o mais do que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e condeno o réu Pablo Gustavo Oliveira Conceição como incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. o art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 739 (setecentos e trinta e nove) dias-multa, no mínimo legal.

Defiro o recurso em liberdade, tendo em vista que o réu respondeu parte do processo em liberdade.

Com o trânsito em julgado, anote-se o resultado definitivo no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, TRE e Guia à VEC nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, nos termos do artigo 63, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Tendo sido assessorado pela defensoria pública, defiro ao réu a gratuidade de justiça.

P.I.C.

Franco da Rocha, 12 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA